

1500904-70.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... em sede definitiva, por crime de tráfico de drogas, não sendo, portanto, primário e portador de bons antecedentes, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Noutro giro, é o caso de absolver o imputado da prática do crime da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

A configuração dessa modalidade especial de associação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500904-70.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500904-70.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito Substituto: Dr. LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ERICK VINÍCIUS FARIAS PEREIRA e MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (fls. 87/91), qualificado nos autos, dando-os como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática dos seguintes fatos delituosos:

(i) Em data incerta, mas certamente antes de 04 de abril de 2021, em horário incerto, mas na cidade de Itapecerica da Serra, os denunciados, agindo consciente e voluntariamente, se associaram para a prática reiterada do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006.

(ii) No dia 04 de abril de 2021, por volta das 14h30min, na Estrada Mombaça, altura do nº 50, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 208 "Eppendorf" contendo cocaína, com peso líquido de 48,1g, 170 porções de crack, com peso líquido de 22,7g, 43 porções de maconha, com peso líquido de 58,4, drogas

estas que causam dependência química e física, além de R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 14/16 e laudo definitivo a ser oportunamente anexado ao feito. A denúncia foi recebida em 13.05.2021, e foi decretada a prisão preventiva dos réus (fls. 104/106).

Regularmente notificado (fls. 139/140), o denunciado Mateus Pereira de Oliveira apresentou defesa prévia, por intermédio de defensora nomeada, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 144/158).

Restando infrutíferas as diligências para cumprimento do mandado de prisão em desfavor do réu Erick, ele foi citado por edital (fls. 201/204), mas não ofertou resposta à acusação, tampouco constituiu advogado (fl. 205), ao que foi determinada a suspensão do processo em relação a ele, com o subsequente desmembramento do feito (fl. 213).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designaram-se audiências de instrução e julgamento.

Nas datas aprazadas, colheram-se os depoimentos das testemunhas, e o acusado Mateus foi interrogado. Uma vez encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede em parte.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 9/11) e nos autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar das substâncias apreendidas (fls. 12/13 e 14/16), despontando, ainda, do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 223/225). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidas, na bolsa que o acusado Mateus trazia consigo, 208 eppendorfs de cocaína, 170 pedras de crack e 43 porções de maconha, com pesos líquidos de 48,1g, 22,7g e 58,4 g, respectivamente. O exame químico-toxicológico atesta que as substâncias entorpecentes apreendidas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Tanto em solo policial, quanto em juízo (fls. 3 e 4), os dois policiais militares que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, Jofson de Lima Soares e Geraldo Cruz Júnior, ouvidos na condição de testemunhas, apresentaram relatos harmônicos, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Relataram que: estavam em patrulhamento de rotina pela Estrada de Mombaça, altura do nº 50, Jardim São Pedro, quando visualizaram dois jovens caminhando em via pública, os quais demonstraram apreensão ao perceberem a presença da viatura; em revista pessoal, localizaram na bolsa que Mateus trazia consigo uma sacola plástica, em que estavam os entorpecentes apreendidos, e, com Erick, R\$ 215,00 em espécie; indagados informalmente, os agentes admitiram que estavam fazendo a recolha do dinheiro de "biqueiras" da região e abastecendo os pontos com drogas.

Silente na senda policial (termo de fl. 8), o acusado confessou parcialmente em juízo os fatos imputados, admitindo a traficância, na modalidade de guardar as drogas, mas negando a associação para a mercancia ilícita (mídia audiovisual da segunda audiência).

Como se vê, os seguros, claros e congruentes testemunhos dos policiais militares, que têm eficácia probatória amplamente reconhecida pela jurisprudência de há muito consolidada pelos tribunais superiores - sobretudo em casos como o presente, envolvendo o tráfico de drogas, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu (como na espécie, até porque não o conheciam) -, aliados à confissão parcial do réu, formam quadro probatório suficiente à formação da autoria delitiva.

Embora o réu meneie a tese de que o flagrante foi "forjado" pelos policiais, tal argumentação não é minimamente crível. Foi apreendida quantidade razoável de

substâncias entorpecentes de natureza diversificada – sendo que um flagrante por tráfico poderia ser “fabricado” com uma quantidade consideravelmente inferior, caso fosse esse o intento dos agentes públicos -, e a origem lícita e as razões para o armazenamento das drogas em poder do imputado não foram comprovadas nos autos. Nesse cenário, a defesa não comprovou o fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva alegado (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a tese da absolvição por falta de provas da autoria.

Tampouco se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo, tenha em depósito ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Assentadas a materialidade e a autoria delitivas, resta operar a qualificação jurídico-penal dos fatos.

Consoante acima exposto, restou configurado, estreme de dúvidas, o tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

Consta de fls. 211/212 que o acusado foi condenado criminalmente em momento anterior, em sede definitiva, por crime de tráfico de drogas, não sendo, portanto, primário e portador de bons antecedentes, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Noutro giro, é o caso de absolver o imputado da prática do crime da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

A configuração dessa modalidade especial de associação criminosa exige que ao menos duas pessoas se agrupem de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 34 (tráfico de maquinário) da Lei nº 11.343/2006. É a constatação desse vínculo subjetivo duradouro que se presta a distinguir o mero concurso eventual e episódico de pessoas do crime autônomo do art. 35 da Lei de Drogas.

Daí pontificarem ALICE BIANCHINI, LUIZ FLÁVIO GOMES, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA que “a consumação, que se dá com a formação da sociedade criminis, protraí-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente). Como já alertado acima, não há necessidade de que algum dos delitos venha a ocorrer, desde que demonstrado que a associação de pessoas continha um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade.” (Legislação criminal especial – 2. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – Coleção ciências criminais, vol. 6 – coordenação Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha, p. 265).

O Ministério Público não demonstrou o vínculo associativo estável, duradouro e

permanente entre o acusado e o comparsa, tampouco assinalou com qualquer relato de investigação anterior sólida e específica tendente a apurar a caracterização da *societas sceleris* entre eles, elucidando a ocorrência do delito do art. 35 da Lei de Drogas.

Como destacou o eminente Desembargador Guilherme de Souza Nucci na Revisão Criminal nº 0005607-96.2020.8.26.0000, julgada pelo 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 18.12.2020, em acórdão de sua relatoria, “a vinculação traficância e associação não é automática, requerendo, para tanto, provas no sentido de demonstrar a estabilidade e a permanência do agrupamento, parte dos seus membros, o papel por cada um desempenhado, não obstante a desnecessidade de haver habitualidade, ou seja, não se exige o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos artigos 33 e 34, da Lei em comento. A associação não deve ser extraída de um fato isolado, requerendo, para sua comprovação, investigação mais apurada. (...). O Estado precisa efetivamente investigar os fatos, não cabendo ao Poder Judiciário extrair de uma apreensão a existência presunçosa de permanência e estabilidade de uma associação.”

Nesse quadro de insuficiência probatória, impõe-se a absolvição do acusado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por força do princípio do *in dubio pro reo*.

Aperfeiçoou-se, assim, a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo CP (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, a natureza (crack, cocaína e maconha) e a quantidade não exorbitante das drogas não ensejam maior reprovação penal. Noutro giro, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitativa; o réu ostenta duas condenações criminais anteriores transitadas em julgado por tráfico de drogas (fls. 211/212), uma por fato posterior ao presente, que, embora não configure reincidência, encarna mau antecedente; o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista do mau antecedente, exaspero a pena-base em 1/8, fixando-a em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

Na segunda fase, concorrem as circunstâncias atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, “d”, do CP), consistente em “admitir contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso” (NUCCI, Guilherme de Souza - Código Penal Comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 396), utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545 do STJ), bem como a agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63, ambos do CP) em crime de tráfico de drogas – conforme acima se adiantou.

Atento à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso a atenuante com a agravante, posto serem igualmente preponderantes, *ex vi* do disposto no art. 67 do CP, remanescendo a sanção inalterada.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento de pena, ao que torno a pena intermediária anteriormente fixada definitiva em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, porquanto a pena supera 4 anos de reclusão, e se trata de réu reincidente específico e portador de mau antecedente (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e Súmula nº 269 do STJ, a contrario

sensu).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, seja pela quantidade de pena imposta, seja em razão da reincidência específica do acusado (arts. 44 e 77 do CP, a contrario sensu).

Com relação à detração penal, entendo que eventual pedido nesse tocante deve ser avaliado pelo juízo das execuções, competente para tanto. Nessa linha:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Denego, por fim, o direito ao apelo em liberdade. Da gravidade concreta do crime e da reincidência do réu emerge que, caso solto, ele poderá colocar em xeque a tranquilidade social, de vez que terá os mesmos estímulos para delinquir. No preciso escólio de NORBERTO AVENA:

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir.

(...)

Neste mesmo prisma, Guilherme de Souza Nucci, aduzindo, quanto à garantia da ordem pública, que se entende pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (Processo Penal - 11. ed. - Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 1.004).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para:

(a) ABSOLVER o réu MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita por incurso no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP; e (b) CONDENÁ-LO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 563 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da segregação cautelar, continuará custodiado (art. 387, § 1º, c.c. art. 312, ambos do CPP), devendo ser recomendado, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso), e não houve requerimento explícito da acusação nesse tocante.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do agente em favor da

União, o que faço com supedâneo no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração – caso ainda não tenha sido realizada.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor da patrona nomeada, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados;

(b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c)

expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do CP).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica da Serra, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA